

1500521-08.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Salomão Spinelli

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... a desclassificação do delito de tráfico, mas sem a plausibilidade necessária que deve saltar aos olhos do julgador, quando a referida versão deveria guardar verossimilhança entre o remanescente do conjunto probatório reunido nos autos. Com efeito, não havendo critério objetivo para a distinção entre o crime de tráfico de drogas e o de uso pessoal, deve o Magistrado valer-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

2ª Vara

Rua Capitão Bonfim, 273, Tanabi - SP - cep 15170-000

1500521-08.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500521-08.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNA APARECIDA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Salomão Spinelli

Vistos.

BRUNA APARECIDA DOS SANTOS foi presa em flagrante, denunciada e está sendo processada por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 09 de abril de 2021, por volta das 17h21min, na Rua Acre, nº 43, Centro, no Município e Comarca de Tanabi, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 58 (cinquenta e oito) pedras de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 9,3 gramas (nove gramas e trezentos miligramas), droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi concedida liberdade provisória à acusada (fls.97/98).

Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 8/9).

Laudo pericial de exame químico toxicológico (fls. 124/127).

Auto circunstanciado de incineração de substâncias entorpecentes (fls. 145/147).

A ré foi citada (fls. 155), apresentando rdefesa prévia (fls. 141/143).

A denúncia foi recebida aos 11.3.2022 (fls. 160/163).

Na audiência de instrução realizada aos 19.7.2022, na sala de audiências virtual da 2ª Vara do Foro de Tanabi, Comarca de Tanabi, Estado de São Paulo, por meio da plataforma Microsoft Teams, foram inquiridas as testemunhas comuns Rosângela de Souza Mendes e Marcelo José da Silva, além da testemunha de defesa Osemira Aparecida Alves de Oliveira. Em seguida, a acusada foi interrogada. Encerrada a instrução, pelas partes foi requerida a concessão de prazo para apresentação de memoriais escritos, o que foi deferido.

O Ministério Público apresentou memoriais finais (fls. 228/234) pugnando pela procedência da ação penal e a consequente condenação da ré.

A defesa também apresentou memoriais (fls. 237/247) pugnando pela absolvição da acusada por insuficiência de provas no que se refere à suposta comercialização do entorpecente apreendido, com fundamento legal no princípio do in dubio pro reo, desclassificando a conduta de tráfico para uso próprio, consoante o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, aplicando assim a medida de advertência. Eventualmente, em caso de condenação, seja concedido a acusada o redutor máximo previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão penal é procedente. Se não vejamos:

A materialidade do crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 restou comprovada pelo(a)s auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/3), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 8/9), auto de exibição e apreensão (11/12), laudo pericial de exame químico toxicológico (fls. 124/127) e pelas demais provas orais produzidas nos autos.

De fato, o exame químico toxicológico das substâncias apreendidas em poder do acusado revelou resultado positivo para cocaína, substâncias listadas em Portaria 344/1998 SVS/MS - Lista F1 e F2 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil), conforme fls. 124/127.

Em relação à autoria também não restam dúvidas.

A testemunha comum Rosângela de Souza Mendes, policial militar, afirmou, em Juízo, que no dia dos fatos foram acionados via COPOM em razão de uma denúncia de que uma mulher de nome Bruna, pele morena, cabelo de tranças e alta, que morava em Ecatu, havia recebido uma certa quantidade de entorpecentes e iria distribuir pela cidade. Quando estavam próximos a Ecatu, receberam outra denúncia de que a mesma pessoa de nome Bruna havia recebido uma arma além dos entorpecentes, e que ambos estariam guardados dentro de seu guarda-roupas. Em diligência até o endereço, os policiais foram recebidos pela própria acusada, explicaram o que estava acontecendo e a acusada chamou sua mãe, que estava na residência da frente. A mãe da acusada autorizou a entrada dos policiais no interior da residência e, em vistoria no quarto de Bruna, foi localizado dentro do guarda-roupas em um pote plástico com 58 pedras de crack, havia também folhas de caderno com nomes de pessoas e valores. Alguns desses nomes se referiam a pessoas já conhecidas nos meios policiais.

Armamento nenhum foi encontrado. Diante dessa situação, a acusada foi conduzida até a Delegacia. Relatou que na abordagem, a acusada disse que estaria guardando a droga para alguém. Não conhecia a acusada anteriormente aos fatos.

A testemunha comum Marcelo José da Silva, policial militar, afirmou, em Juízo, que no dia dos fatos estava em serviço juntamente com a cabo Rosângela pelo Município de Tanabi. Receberam uma denúncia via COPOM informando que no Distrito de Ecatu, uma mulher de nome Bruna, pele morena, forte e com tranças no cabelo, havia recebido uma certa quantidade de droga e que a mesma se encontrava no interior da sua residência, mais precisamente dentro do guarda-roupas, além de que essa droga seria posteriormente distribuída pelo Distrito. Diligenciaram até o local e foram recebidos pela própria acusada. Explicaram a situação e Bruna pediu para chamar sua mãe na residência em frente. A mãe de Bruna atendeu a equipe policial e autorizou a entrada na residência. Adentrando no local, foi até o quarto de Bruna e conseguiu encontrar um pote de plástico contendo 58 pedras de crack. Posteriormente, em uma gaveta no mesmo quarto, fora encontrada a quantia de R\$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais) em notas diversas. Questionada a acusada não soube informar a procedência da droga. Diante dos fatos, foi conduzida até a Delegacia. Acrescentou

que no caminho até a residência da acusada, receberam outra denúncia de que também havia uma arma de fogo no local. Além de que também foi apreendido próximo a carteira da acusada, algumas anotações com nomes de pessoas já conhecidas nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas.

A testemunha de defesa Osemira Aparecida Alves de Oliveira, mãe da acusada, em juízo, confirmou que no dia dos fatos fora encontrado o entorpecente no quarto da Bruna. Relatou que a acusada era usuária de drogas há dois anos e por isso comprava o entorpecente escondido para sustentar seu vício. A acusada trabalhava na roça na época dos fatos. O dinheiro estava com a Bruna, pois lhe havia pedido para que pagasse uma conta. Atualmente a acusada trabalha na área de limpeza da prefeitura. Confirmou que autorizou a entrada dos policiais na residência.

A acusada Bruna Aparecida dos Santos, em seu interrogatório, negou as acusações a ela imputadas, dizendo que apenas é usuária de drogas e que os entorpecentes apreendidos eram para seu uso. Nada tem contra as testemunhas e nunca foi presa ou processada anteriormente. Trabalha com limpeza para a prefeitura. Afirmou que os papéis apreendidos com nomes e valores se referia a vendas de roupas íntimas, roupas de banho, toalhas, que inclusive vende até os dias de hoje. Na época dos fatos trabalhava na roça e recebia R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) semanais. Relatou que consumia dez pedras de crack por dia e pagava R\$ 5,00 (cinco reais) por cada uma delas.

O relato oferecido pelos policiais foi extremamente detalhado, firme e coeso, não pairando nenhuma dúvida acerca dos fatos por eles narrados.

As alegações da ré, por sua vez, de que a droga encontrada era para o seu consumo pessoal, restaram isoladas e desacreditadas nos autos. Vê-se que a acusada pretende a desclassificação do delito de tráfico, mas sem a plausibilidade necessária que deve saltar aos olhos do julgador, quando a referida versão deveria guardar verossimilhança entre o remanescente do conjunto probatório reunido nos autos. Com efeito, não havendo critério objetivo para a distinção entre o crime de tráfico de drogas e o de uso pessoal, deve o Magistrado valer-se da análise das circunstâncias do caso.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que a acusada guardava e tinha em depósito 58 (cinquenta e oito) pedras de cocaína, na forma de crack, e não houve demonstração nos autos de que tinha condições financeiras de adquirir tamanha quantidade de droga.

Tais circunstâncias divergem daquelas em que corriqueiramente são tipificadas como uso de drogas, ou seja, quando há apreensão de poucos cigarros de maconha ou quantia bastante para uso diário e individual.

Além disso, a condição de usuário não obsta a condenação por tráfico quando as circunstâncias evidenciam que o ânimo do agente era o comércio ilícito de entorpecente, posto que os usuários, frequentemente, passam a traficar para sustentar o vício.

Ressalto que, além da droga, foram apreendidas na residência da acusada três folhas de papel com diversas anotações com nomes de pessoas, valores e telefones, o que evidência a finalidade da traficância.

Outrossim, a oitiva dos policiais que conduziram a ocorrência está em consonância com o contexto probatório produzido nos autos, portanto, ao contrário do que alega a Defesa, serve como meio de prova para embasar sentença condenatória. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES COMETIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.368/76. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO LACÔNICA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90. REGIME PRISIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE. 1. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do

paciente sejam considerados na sentença como meio de prova para embasar a condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese. 3. (...) (HC 166.124/ES, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 09/08/2012).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE DEFERIDA. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO QUE DEVE SER COMPREENDIDA DENTRO DOS LIMITES RECURSAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, NULIDADE ABSOLUTA OU TERATOLOGIA A SER SANADA. ORDEM DENEGADA. I.(...) V. O presente caso não revela a ocorrência de qualquer situação de flagrante ilegalidade, nulidade absoluta ou teratologia a ser sanada pela via do habeas corpus. VI. Condenação do ora paciente pela prática do crime de roubo que não se baseou, exclusivamente, em provas produzidas durante a fase inquisitorial, já que a sentença foi lastreada, de igual modo, em depoimento prestado em juízo por policial civil, sem que se vislumbre a indigitada nulidade na sentença condenatória. VII. (...) IX. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. (HC 229.529/SC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012).

Assim, há prova suficiente de que a acusada guardava, para o fim de oferecer, vender e entregar ao consumo de terceiros, 58 (cinquenta e oito) pedras de cocaína na forma de crack.

Isso posto, passo à fixação da pena.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sobretudo a ausência de maus antecedentes (cf. fls. 92) aptos a majorar a pena, fixo a pena base em cinco anos de reclusão. Não há agravantes e eventuais atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Também não há causas de aumento. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06 é aplicável porque a acusada é primário, não tem maus antecedentes e não há prova de que integre organização criminosa, de modo que reduzo a reprimenda em dois terços, perfazendo-se um ano e oito meses de reclusão.

Observo que o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, na hipótese, se impõe porque, além dos fatos descritos acima, a quantidade de droga apreendida em poder da ré não é exorbitante, tampouco é diversificada, do que se extrai que não se trata de grande operação de comércio ilícito de entorpecente, mas de pequeno fornecedor.

Reconheço, consoante entendimento do E. STJ (Tema 600), não se tratar de crime hediondo, posto que reconhecida a figura do tráfico privilegiado, o que viabiliza, inclusive, conforme precedentes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Nesse sentido já se decidiu: HC 596.603/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020.

Por tais razões, nos termos do artigo 33, § 2.º, do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena.

Presentes os pressupostos do artigo 44 do Código Penal, nos termos do § 2.º do aludido dispositivo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, ou seja, duas prestações pecuniárias no valor de R\$1.212,00 cada.

Por sua vez, não é viável a realização da detração para fins de regime prisional diretamente nesta sentença, porquanto, não obstante o disposto no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, ausentes elementos suficientes nos autos para sua concessão, especialmente o requisito subjetivo que só pode ser devidamente analisado pelo Juízo das Execuções Criminais. Nesse sentido temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça:

"(...) embora não se desconheça o teor da Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º ao artigo 387, do Código de Processo Penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos recorrentes, isto é, se não registram outras condenações ou

prisões processuais nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à mingua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição (...)." (Apelação nº 0009573-71.2012.8.26.0348, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juvenal Duarte, j. 13.02.2014);

"Assim, se pode concluir que a intenção do legislador foi positiva, mas a execução da medida deixou a desejar, considerando a redação final do dispositivo (...). Grande dificuldade prática decorre da aplicação literal desse mandamento: se o Magistrado prolator da sentença condenatória considerar o tempo de prisão processual cumprido, a ser detraído do total, para fixação do regime inicial, estaria por conceder verdadeira progressão de regime prisional, fazendo-o, todavia, sem acesso às eventuais intercorrências da execução penal, ainda que provisória. Assim, fixaria regime mais brando em razão do tempo de pena cumprido, sem analisar o comportamento carcerário do condenado. Não bastasse isso, ao receber o processo, o Juiz das Execuções teria que conceder uma progressão de regime verdadeira quase que imediatamente, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, para que o preso passe do regime fixado na sentença (o regime inicial de cumprimento) para o mais brando. Na prática, nessa hipótese, haveria duas concessões de progressão de regime, a primeira delas sem análise do requisito subjetivo, mas ambas com base no mesmo tempo de cumprimento da pena (que seria considerado duas vezes em favor do condenado, em evidente ilegalidade)". (TJSP, HC n. 0152636-97.2013.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Otávio de Almeida Machado, julgado em 22.10.2013).

Relativamente à pena de multa, considerando os mesmos fatores já expostos, fixo-a em cento e sessenta e seis dias-multa com valor unitário no mínimo legal.

Em relação ao perdimento de bens deve ser observado o regramento contido nos artigos 91, II, do Código Penal e 60 e 62 da Lei 11.343/06, de modo que apenas aqueles que, comprovadamente, forem: (i) "instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito"; (ii) "produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso"; e (iii) "veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei" de Drogas.

Posto isso, verifico que a quantia em dinheiro de R\$186,00 em dinheiro e as folhas de papel (fls11/12) apreendidas com a ré devem ter seu perdimento decretado, porquanto comprovadamente valor auferido em proveito da prática delituosa e instrumentos do crime, especialmente por se tratar de notas diversas.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão penal e, assim, pela prática do crime descrito no artigo 33, "caput" e § 4º, da Lei 11.343/06, CONDENO BRUNA APARECIDA DOS SANTOS às penas de dois anos de reclusão em regime aberto e cento e sessenta e seis dias-multa com valor unitário no mínimo legal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, ou seja, duas prestações pecuniárias no valor de R\$1.212,00 cada.

À ré foi concedida a liberdade provisória e não houve alteração fática, portanto, poderá recorrer em liberdade.

Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006 e conforme supra fundamentado, decreto o perdimento definitivo da quantia de R\$186,00 em dinheiro de fls. 119, que deverá ser revertida diretamente ao Funad - Fundo Nacional Antidrogas, nos termos do Art. 63, §1º da Lei 11.343/2006.

Os entorpecentes deverão ser destruídos imediatamente, preservando-se apenas as amostras até o trânsito em julgado.

Transitada em julgado: (i) proceda-se à transferência da quantia depositada a fls. 119 ao Funad; e, (ii) oficie-se à autoridade policial autorizando a destruição da amostra da droga apreendida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tanabi, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA